

第20問

甲は、A（28歳、男）のことを恨んでおり、殺してやろうと思い、そのことを乙に相談した。乙は、これに対して、「この睡眠薬は、10錠飲めば意識が戻らずに死亡する代物だ。これをAに飲ませて殺すのはどうか。」などと言って、睡眠薬10錠を交付した。

この睡眠薬は、過剰に投与されれば身体に重篤な症状を与え、場合によっては死亡する可能性もあるものであったが、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは、死亡する確率は皆無であった。乙もそのことを認識しており、甲に渡した睡眠薬10錠では、健康であるAを殺害することはできないと思っていたが、甲がこれをAに飲ませれば少しは恨みも晴れるだろうと考えて、甲に交付したのであった。

しかし、甲は、この睡眠薬を10錠飲ませればAが死亡すると信じ、Aに乙から渡された睡眠薬10錠を飲ませた。その結果、Aは、深い眠りにつき、起きた後も、眠気により意識が朦朧とすることがあったが、数日後には回復した。

甲及び乙の罪責について、論じなさい。

第1 甲の罪責

1 本件睡眠薬は、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは死亡する確率は皆無であるから、甲がAに対して睡眠薬10錠を飲ませた行為が、殺人未遂罪（203、199）に当たるかが問題となる。いわゆる不能犯の問題である（**論点** 不能犯  司H30,予H29）。

 108頁  42頁

2 不能犯と未遂犯の区別については、学説上、具体的危険説と客観的危険説の対立がある。客観的危険説の中でも、純客観的に危険性の有無を判断する立場と、何らかの形で修正を加えて危険性の有無を判断する立場がある。

具体的危険説は、行為時に一般人が認識し得た事情および行為者が特に認識していた事情を基礎として、一般人の法則的知識を基準に危険性を判断する。

純客観的危険説は、裁判時に判明した全ての事情を基礎として、科学・専門的知識を基準に危険性を判断する。

修正された客観的危険説には様々なバリエーションがあるが、結果不発生の原因を事後的、科学的に明らかにした上で、結果を発生させる事実がどの程度存在したかを問う立場が有力である。

本件睡眠薬は、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは死亡する確率は皆無であるが、過剰に投与されれば身体に重篤な症状を与え、場合によっては死亡する可能性もあるものであるから、具体的危険説からは危険性の発生が肯定できるだろう。

一方、純客観説からは、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは、死亡する確率は皆無である以上、危険性の発生を肯定することは難しい。

修正された客観的危険説からは、この睡眠薬10錠が過剰投与される可能性（事案からは明らかではないが、Aの体調次第で重篤な症状が生じるのであれば、Aの体調不良が生じる可能性）を考慮することになるだろう。

なお、殺人未遂罪の成立を否定したとしても、Aには数日間眠気により意識が朦朧とするなどの生理的障害が生じているから、傷害罪（204）は成立することになるだろう。

3 判例は、絶対不能か、相対不能かという基準により判断しているといわれることもあるが、その具体的基準は明らかではない。最判昭37.3.23【百選166】は、殺意をもって被害者の静脈に致死量以下の空気を注射した事案で「空気の量が致死量以下であっても被注射者の身体的条件その他の事情の如何によっては死の結果発生の危険が絶対にはない」として、殺人未遂罪を肯定しており、本問との関係でも、参考になるだろう。

第2 乙の罪責

1 甲に殺人未遂罪を成立させた場合、乙には同罪の幫助犯（62 I）が成立する可能性がある。

2(1) もっとも、乙は本件が未遂に終わることを認識しているため、この場合でも幫助犯の故意が認められるかが問題となる（**論点** 未遂の教唆  旧H17-1）。

(2) この点は、学説上、肯定説、否定説ともに有力に主張されているた

 128頁  49頁

め、いずれの立場に立ってもかまわない。

- 3 ただし、乙にも人の生理的機能を害する旨の認識はあるから、傷害罪の幫助犯は成立する。

答案構成

第1 甲の罪責

1 殺人未遂罪（203、199）の成否

↓

2 不能犯の成否

↓

具体的危険説

↓

あてはめ

↓

3 殺人未遂罪成立

第2 乙の罪責

1 殺人未遂罪の幫助犯（62 I）の成否

↓

2 未遂の幫助

↓

不可罰説

↓

3 傷害罪の幫助犯は成立

第1 甲の罪責

1 甲が、殺意をもってAに対して睡眠薬10錠を飲ませたものの、その目的を遂げなかった行為について、殺人未遂罪（203条、199条）の成立が考えられる。

2(1) 本件睡眠薬は、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは死亡する確率は皆無である。

そこで、甲の行為は、およそ殺人罪の危険性を有しない行為であって、「実行」に「着手」（43条本文）したとは認められないのではないか。いわゆる不能犯として、処罰の対象にならないのではないかが問題となる。

(2) 不能犯が不処罰とされる根拠は、法益侵害ないし構成要件の実現に至る現実的危険性を欠いた点に求められる。

したがって、不能犯と未遂犯の区別は結果発生の危険性の有無に求められる。

それでは、そのような危険性の有無はいかに判断すべきか。

構成要件は一般人への行為規範であるから、一般人の視点から判断して結果発生の危険性がある場合は処罰すべきである。また、基礎事情として特に行為者が知っていた事情を取り込まなければ、帰責の範囲において妥当な結論を導くことはできない。

以上から、行為時に一般人が認識し得た事情、及び行為者が特に認識していた事情を基礎にして、一般人を基準に具体的危険の有無を判断するのが妥当である。

1

(3) 本件睡眠薬は、健康な成人男性が10錠飲んだだけでは死亡する確率は皆無であるが、過剰に投与されれば身体に重篤な症状を与え、場合によっては死亡する可能性もあるものである。

一般人が認識し得た事情としては、健康な成人男性であるAに対して、このような危険性を有する睡眠薬を10錠も飲ませるというものであり、一般人からすると、10錠という服用数は睡眠薬のそれとしては多量といえる以上、死亡の危険を惹起する可能性が皆無とはいえない。

3 したがって、甲は不能犯とはならない。

よって、「実行」に「着手」したものとして、殺人未遂罪が成立する。

第2 乙の罪責

1 乙が甲に対して睡眠薬10錠を交付した行為について、「正犯を幫助した」として、殺人未遂罪の幫助犯（62条1項）が成立するとも思える。

(1) もっとも、乙はAの死亡結果が発生する可能性がないこと、すなわち、殺人が未遂に終わることを認識している。このように、共犯者に結果の発生の認識がない場合、故意責任（38条1項本文）を問うことができるか。

(2) 共犯の処罰根拠は正犯を通じて、間接的に法益侵害の結果又はその危険を発生させる点に求められるから、正犯と共犯の処罰根拠は基本的には同一であると解される。

2

そうだとすれば、正犯において結果の発生の認識まで必要とされている以上、共犯においても別異に解すべき理由はない。

したがって、共犯者に結果発生の認識が無い場合、故意責任を問うことはできない。

2 本問でも、乙は殺人罪の幫助犯の故意を欠くから、殺人未遂罪の幫助犯にはならない。

3 もっとも、乙は、眠気により意識が朦朧とするなど、Aの生理的機能を害する旨の認識はあるだろうから、傷害罪（204条）の故意を有する。

したがって、同罪の幫助犯は成立する。

以上

3

4